

1506612-26.2021.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Marina Freire

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/02/2022

... provas seguras da prática dos delitos de roubo pelo réu.

Alijando a matéria preliminar aventada, passo à análise do mérito.

Em que pese os esforços empreendidos pela ilustre Defesa, o conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à pretensão deduzida na denúncia, para condenação do réu pelos delitos de roubo majorado.

A materialidade delitativa veio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506612-26.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL HENRIQUE DIAS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marina Freire

Vistos.

RAFAEL HENRIQUE DIAS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das 23h14, na rua César Cruz Ciafrei, n. 900, Jardim Chapadão, nesta cidade e Comarca de Bauru, agindo em concurso e unidade de desígnios com Ryan Carlos Baroni Miotto e Jonathan William Rocha, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, a quantia de R\$ 1.000,00, além de maços de cigarro, pertencentes ao estabelecimento "Casa da Cerveja", de propriedade de Willian de Oliveira Leal.

Ainda, consta, segundo a denúncia, que RAFAEL HENRIQUE DIAS e JHONEY LEONARDO DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados

como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 15 de maio de 2021, por volta das 23h30, nas mesmas circunstâncias de local acima descritas, adrede combinados e com unidade de propósito, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o valor de R\$ 2.800,00, pertencentes à empresa "Casa da Cerveja".

A denúncia foi oferecida (fls. 1/4) e recebida pela decisão de fls. 2082, que, outrossim, determinou a citação dos réus.

A decisão de fl. 35 deferiu o pedido da Autoridade Policial para autorizar o acesso aos dados contidos no aparelho celular pertencente ao indiciado Rafael Henrique.

Foi decretada a prisão temporária do réu Rafael Henrique às fls. 28/29 do apenso n. 1506610-56.2021.8.26.0071, conforme fls. 14/19 destes autos principais.

Por decisão de fls. 2008/2010, foi decretada a prisão preventiva do réu Rafael Henrique.

Os réus foram citados (Rafael Henrique: fl. 2119; Jhoney Leonardo: fl. 2127) e apresentaram resposta à acusação às fls. 2138/2140.

A decisão de fls. 2147/2150 designou Audiência de Instrução, Debates e Julgamento, bem como deferiu a instauração do incidente de exame de dependência toxicológico requerido pela Defesa em favor de Jhoney Leonardo.

Deu-se início à fase de instrução, procedendo-se à oitiva de três vítimas, de duas testemunhas comuns e, ao final, aos interrogatórios dos réus (fl. 2205-mídia).

Encerrada a fase de instrução, as partes passaram às alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, pois entendeu comprovadas a autoria e a materialidade delitivas em relação aos réus (fls. 2209/2216).

Por outro lado, a Defesa dos réus rogou pela absolvição diante da ausência de provas e de elementos a corroborar um édito condenatório, destacando que o reconhecimento realizado em solo policial assim como aquele feito em juízo não observaram as garantias previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, bem como sustentou a impossibilidade de combinação das causas de aumento de pena do artigo 157, §2º e §2º-A, do Código Penal ou, ainda, a aplicação da Teoria da Incidência Isolada. Por fim, postulou a fixação do regime inicial diverso do fechado, observado o disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal e, como o acusado Jhoney é primário e não registra antecedentes criminais, pugnou seja fixado o regime inicial aberto, além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a ambos os acusados (fls. 2220/2240).

A decisão de fl. 2246 determinou o desmembramento dos autos com relação ao denunciado Jhoney Leonardo da Silva Santos.

Assim, este feito prosseguiu somente contra o réu RAFAEL HENRIQUE DIAS

Tendo em vista o desmembramento realizado, o despacho de fl. 2252 deu vista dos autos às partes para ratificação das alegações finais apresentadas.

O Ministério Público nada acrescentou às alegações finais de fls. 2209/2216, conforme manifestação de fl. 2256.

A Defesa dos réus reiterou os memoriais anteriormente apresentados (fl. 2259).

É o relatório.
DECIDO.

Cuida-se de ação penal instaurada para apuração dos delitos de roubo majorado.

Por primeiro, repilo a preliminar de nulidade ventilada pela combativa Defesa, tendo em vista que o reconhecimento formalizado pelas vítimas em solo policial, bem como aquele realizado em juízo, não são eivados de irregularidade, uma vez que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal é mera recomendação legal a ser observada quando possível.

Nessa esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART.157, § 2º, I E II, CP. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO STJ. ARTS. 155 E 386, IV, DO CPP. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO COM MOTIVAÇÃO IDÔNEA E AMPARO EM AMPLO CONTEXTO PROBATÓRIO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei. Precedentes. 2. O Tribunal estadual consignou que o conjunto probatório dos autos, notadamente os depoimentos das vítimas e das testemunhas ouvidas em juízo, não deixa dúvida de que foi o ora agravante o autor do delito, e que a tese de negativa de autoria se encontra totalmente divorciada das provas colhidas nos autos; entender de forma diversa, tal como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação da Súmula7/STJ.3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp1054280/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017).

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais previstas no art. 226 do CPP não perdeu seu valor probatório, servindo como importante elemento de convicção do juiz, pois as determinações constantes no dispositivo legal mencionado, embora sejam aconselháveis, não são reputadas como essenciais. (TACRIM-SP AP Rel. Penteado Navarro RT678/337).

Assim sendo, qualquer irregularidade havida na fase policial restou ultrapassada, observado que, sob o crivo do contraditório, as vítimas reconheceram o acusado como autor dos roubos, na presença das partes, tratando-se de meio de prova válido, de qualquer forma, consabido é que o inquérito policial não contém ato jurisdicional e, consequentemente, seus vícios não afetam a ação penal posterior.

In casu, o reconhecimento realizado pelas vítimas vem corroborado por outros elementos, existindo provas seguras da prática dos delitos de roubo pelo réu.

Alijando a matéria preliminar aventada, passo à análise do mérito.

Em que pese os esforços empreendidos pela ilustre Defesa, o conjunto probatório é contundente e apto a dar arrimo à pretensão deduzida na denúncia, para condenação do réu pelos delitos de roubo majorado.

A materialidade delitativa veio estampada pelos boletins de ocorrência de fls. 8/9, 10/13, 366/368 e 2097/2098, autos de exibição e apreensão de fls. 22 e 1987, laudo pericial de fls. 372/385, dados extraídos do aparelho celular apreendido de fls. 39/348 e 386/1968, relatórios de investigação de fls. 350/359 e 362/363, relatórios

finais de fls. 1993/1997 e 2100/2102, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A imputação da autoria dos delitos ao réu é igualmente inarredável, pois fruto da prova colhida em Juízo, sob a égide do princípio do devido processo legal, assegurando, de forma imperiosa, o contraditório e a ampla defesa.

Vejamos:

O réu RAFAEL HENRIQUE confessou ter participado apenas do segundo roubo, negando seu envolvimento no primeiro crime. Esclareceu ter praticado o delito para sustentar o vício em entorpecentes. Acrescentou estar desempregado e necessitar de dinheiro para o adimplemento de pensão alimentícia. Mencionou ter sido preso por roubo anteriormente. Revelou ter convidado Jhoney Leonardo para participar da empreitada criminosa, haja vista que ele possuía uma motocicleta. Declarou que a arma tratava-se de um simulacro, bem como tomou conhecimento de que a mesma havia sido dispensada (fl. 2205-mídia).

Por sua vez, o réu JHONEY LEONARDO disse que se encontrou com corréu Rafael a fim de fazerem uso de entorpecentes, ocasião em que decidiram comprar um simulacro. Ato contínuo, saíram em busca de algum lugar onde pudessem subtrair algo, localizando a adega. Declarou que, após o roubo, cada um deles ficou com parte do dinheiro, tendo, em seguida, adquirido mais drogas. Acrescentou trabalhar com manutenção (fl. 2205-mídia).

A vítima Willian de Oliveira Leal relatou que, nas duas oportunidades em que o estabelecimento de sua propriedade foi roubado, encontrava-se em outra loja, sendo que, em uma das ocasiões estava no comércio a vítima Polyane e, na outra, o ofendido Kennedy, que o comunicaram acerca do ocorrido. Contou que, ao chegar ao local, a quantia já tinha sido levada pelos réus. Ato contínuo, ele verificou as imagens das câmeras de monitoramento e acionou a Polícia. Esclareceu que o primeiro roubo ocorreu em fevereiro de 2021, próximo ao horário de fechamento, tendo sido avisado pelo funcionário Kennedy, que estava apavorado. Declarou que dois indivíduos chegaram ao local, tendo um deles permanecido na grade e o outro anunciado o assalto, ameaçando o funcionário, com o emprego de uma arma de fogo. Revelou ter obtido imagens de um automóvel modelo Voyage, de cor prata, utilizado pelos réus. Reconheceu o réu Rafael Henrique como autor do crime. Explicou que, por ocasião do primeiro roubo, foram subtraídos mais de R\$ 2000,00, não sabendo precisar a exata quantia roubada no segundo crime. Asseverou que a Polícia Civil o informou tratar-se dos mesmos indivíduos. Acrescentou não se lembrar da participação de algum menor no roubo (fl. 2205-mídia).

No que lhe concerne, a ofendida Polyane Cristina Silva narrou que trabalhava no estabelecimento e, na data dos fatos, abastecia a câmara fria, quando escutou o barulho de uma motocicleta, saindo para efetuar o atendimento, pois acreditava tratar-se de clientes. Ato contínuo, os réus adentraram a loja e anunciaram o assalto, exigindo que ela entregasse o dinheiro. Esclareceu que os réus começaram a revirar todo o estabelecimento, localizando o dinheiro e se evadindo em seguida. Reconheceu o réu Rafael, informando que era ele quem portava a arma no dia do ocorrido. Declarou que o comércio se situa na rua Cézar Cruz Ciafrei. Aduziu que os réus subtraíram aproximadamente R\$ 3.000,00. Explicou que um dos réus vestia uma jaqueta preta e outro usava uma blusa preta com detalhe em azul, sendo este último o que ela reconheceu. Acrescentou que ambos usavam capacete (fl. 2205-mídia).

Já a vítima Kennedy Willian Alves Francisquette disse que trabalhava no mesmo estabelecimento onde a ofendida Polyane é funcionária atualmente, tendo presenciado o primeiro roubo. Esclareceu que, na data dos fatos, após o fechamento da loja, encostou o blindex e a grade. Ato contínuo, dois indivíduos chegaram ao local e bateram à porta, tendo ele feito sinal de que já havia encerrado o horário de atendimento, quando um dos criminosos lhe mostrou o revólver e anunciou o assalto.

Explicou que o réu puxou a grade e a porta de vidro, adentrando a loja. Declarou que o réu o xingou e o empurrou, dizendo que se ele não colaborasse, atiraria contra ele. Revelou que um dos réus permaneceu na porta, enquanto o outro adentrou o comércio para subtrair o dinheiro. Asseverou que nenhum dos réus aparentava ser menor de idade. Reconheceu o réu Rafael, que portava uma arma. Afirmou que o réu levou quase R\$ 3.000,00. Aduziu ter tomado conhecimento de que houve um outro roubo, aproximadamente três meses depois, sendo que os dois crimes ocorreram no estabelecimento localizado na rua Cézar Cruz Ciafrei. Acrescentou que o réu Rafael participou dos dois roubos (fl. 2205-mídia).

O policial civil Mario Koiti Kassama Filho relatou que uma adega foi alvo de roubo por duas vezes, uma em fevereiro e outra em maio de 2021, sendo que, na primeira oportunidade, dois indivíduos foram presos e através das imagens, foi possível verificar o envolvimento de um terceiro. Disse que os indivíduos presos citaram a participação de um terceiro envolvido de prenome Rafael, vulgo "Piru" ou "Pirulito", que, na data do primeiro assalto, ficou fazendo a contenção na parte externa do local; ainda, notou tratar-se de um indivíduo magro de estatura alta. Afirmou que, em maio, houve um novo roubo e dois indivíduos adentram o estabelecimento, um de uma estatura mais avantajada e magro, percebendo uma tatuagem bem nítida, tendo ambos descido de uma motocicleta Honda, de cor vermelha. Esclareceu que, já tendo conhecimento do indivíduo de prenome Rafael, por meio de rede social, conseguiu localizar uma foto dele com a mesma camiseta e tênis que aparecem nas filmagens da câmera de segurança. Ato contínuo, verificou o endereço do réu Rafael e iniciou campana; efetuada a abordagem dele, localizaram, em sua residência, a blusa, o tênis e o capacete usados no roubo. Falou que a atendente reconheceu prontamente o réu na delegacia. Revelou que as tatuagens do réu conferiam com as das imagens das câmeras de monitoramento do local. Declarou que foi apreendido o aparelho celular do réu Rafael, tendo sido solicitada a quebra de sigilo e realizada a perícia, a qual constatou conversas com um indivíduo de prenome Leo, posteriormente identificado como Jhoney Leonardo; além disso, no mesmo dia do fato, houve conversas sugestivas entre o réu Rafael e o corréu Leo, cujas características condiziam com as de seu comparsa. Aduziu que, por meio de redes sociais, o corréu Leo foi identificado como indivíduo que adentrou o estabelecimento e conduziu a motocicleta no dia do ocorrido, tendo confessado a prática do crime, bem como ter se desfeito das roupas e da arma, por tratar-se de simulacro, além de ter vendido o veículo, cuja proprietária era sua genitora. Acrescentou ter constatado muitas semelhanças entre os crimes praticados em fevereiro e maio de 2021, sendo que os horários dos roubos foram similares, uma vez que os réus já conheciam o funcionamento do estabelecimento. Por fim, asseverou que a justificativa dada por Jhoney para a prática do roubo foi o vício em drogas (fl. 2205-mídia).

No mesmo sentido, o policial Michel Walter Alves Redondo disse que recebeu o boletim para investigação de um roubo a um comércio de bebidas na região do Jardim Chapadão. Contou que, de início, o réu Rafael já vinha sendo investigado pela equipe de roubos da DIG por ter sido mencionado em razão de um roubo anterior ao mesmo estabelecimento; na ocasião, três indivíduos teriam praticado o crime, dois foram identificados e presos, contudo não havia detalhes suficientes para indiciar o réu Rafael, conhecido como "Piru". Relatou que, assim que ocorreu o segundo roubo à adega, pelas características do réu, sobretudo as tatuagens, tiveram certeza tratar-se do mesmo indivíduo, que agora praticou o crime com outro comparsa. Ato contínuo, passou a fazer campana próximo à residência do réu Rafael, na qual foram localizados camiseta, tênis e capacete idênticos aos das filmagens das câmeras de monitoramento. Afirmou que a vítima prontamente identificou o réu Rafael. Declarou ter apreendido o aparelho celular do réu Rafael, verificando, por meio de perícia, uma conversa minutos antes do roubo com um indivíduo, que posteriormente foi identificado como Jhoney. Revelou que a genitora do corréu Jhoney é proprietária de motocicleta idêntica à utilizada no roubo, além das semelhanças físicas entre ele e o segundo indivíduo nas imagens. Aduziu que Jhoney

confessou o crime, apresentando como justificativa a dependência em drogas. Asseverou que Jhoney não era conhecido dos meios policiais. Acrescentou que Rafael informalmente comentou que a arma era, em verdade, um simulacro, tendo se desfeito desta, enquanto Jhoney dispensou as vestes usadas na data do crime (fl. 2205-mídia).

Ao que se extrai da prova oral colhida nos autos, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e observada a dinâmica dos fatos, não restam dúvidas de que o réu participou dos crimes de roubo praticados contra um mesmo estabelecimento, nos meses de fevereiro e maio de 2021, empregando grave ameaça e violência para o intento criminoso, sobretudo porque foi reconhecido pelas vítimas.

Neste ponto, é necessário ressaltar que, em crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo é o de que a palavra da vítima prepondera, sendo preciosa e bastante no identificar o autor do delito, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar o verdadeiro culpado e não acusar inocente. Logo, não há se falar que as declarações das vítimas devem ser analisadas com cautela.

Acerca do valor probatório da palavra da vítima em caso como o dos autos, transcrevo:

"Sem dúvida a palavra da vítima é muito importante nos casos em que se apuram delitos como o roubo, pois é ela que teve maior contato com o meliante. Tal entendimento já se encontra cristalizado em nossos Tribunais: 'Prova - Palavra da vítima de roubo - Valor: Em sede de crime perpetrado na clandestinidade, como o roubo, a palavra da vítima deve ser aceita sem ressalvas quando indemonstrado nos autos qualquer interesse, gratuito, de imputar falsa acusação a pessoa inocente, que sequer conhecia anteriormente aos fatos.' (RJTACRIM 15/290)." (TJSP. 4ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0027851-73.2010.8.26.0451. Relator: Desembargador Edison Brandão. Data do julgamento: 18 de março de 2014)

"a palavra da vítima, nos crimes de roubo, ainda que solitária, o que não é o caso dos autos, assume significativa eficácia probatória, porquanto, como é cediço, o seu único desiderato é apontar o verdadeiro autor da infração, e não acusar inocentes, mormente quando não os conhece." (TACRIM-SP-AP-11a C.- Rel. Xavier de Aquino - RJTACRIM 33/218).

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Descabimento: A palavra da vítima representa viga mestra da estrutura probatória e sua exposição firme e segura, com o apoio em outros elementos de convicção, autoriza o édito condenatório. Recurso não provido. (TJSP. 15ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0005515-65.2007.8.26.0068. Relator: Desembargador J. Martins. Data do julgamento: 20 de junho de 2013) (destaquei)

Portanto, nada há a macular as declarações das vítimas, as quais foram claras, coerentes e seguras na descrição do ocorrido.

Além do vasto conteúdo da prova documental e dos depoimentos das vítimas, também merece realce a narrativa dos policiais civis responsáveis pela investigação acerca dos crimes de roubo praticados contra o mesmo comércio de bebidas, os quais relataram detalhadamente como se deram os fatos.

A propósito, nada há nos autos capaz de retirar o valor probatório dos depoimentos dos agentes, cuja essência revelou-se, em sua substância, uniforme e factível em Juízo.

Com efeito, não pode ser desconsiderado o depoimento dos policiais, servidores

públicos cumpridores de seus deveres, já que foram compromissados como qualquer outra testemunha e não possuem interesse em incriminar os réus. Necessário ressaltar que a função da Polícia é prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles. Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais, razão pela qual não merecem ver desprestigiadas suas palavras somente pelo fato de pertencerem ao quadro da Polícia. Nesse sentido:

“Sendo assim, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais militares com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que eles foram submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha. Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades. [...] Ressalte-se que, como é cediço, policiais não estão legalmente impedidos de depor em processos nos quais tenham participado da fase investigativa, revestindo-se suas palavras de relevante valor probatório, mormente quando prestadas em juízo, sob o crivo do contraditório. Ademais, nada de concreto foi trazido aos autos no sentido de infirmar os seus relatos, sendo certo que não teriam razão alguma para imputar a prática de infração tão grave a pessoas que sabem ser inocentes.” (TJSP. 11ª Câmara de Direito Criminal. Apelação nº 0001971-89.2017.8.26.0530. Relator: Salles Abreu. Data do julgamento: 3 de outubro de 2018)

Outrossim, não se pode deixar de constatar que o réu já vinha sendo investigado pela equipe de roubos da Divisão de Investigações Gerais da Polícia Civil por envolvimento em um roubo a um comércio de bebidas ocorrido em 27 de fevereiro de 2021, tendo em vista que, na ocasião, três indivíduos teriam praticado o crime, tendo dois deles sido identificados e presos, contudo, em que pese os outros roubadores tenham mencionado a participação do réu, não havia indícios suficientes para sua autuação à época.

Ocorre que, no dia 15 de maio de 2021, verificou-se a ocorrência de uma segundo roubo ao mesmo estabelecimento e, com fundamento nas características do réu, sobretudo as tatuagens, os policiais concluíram indubitavelmente tratar-se do mesmo indivíduo, que agora praticara o crime com outro comparsa. Assim, após a realização de vigilância e campanas, na data de 17.05.2021, o réu foi localizado na residência situada na Rua das Mangueiras 1-36 e, com a sua autorização, foram efetuadas buscas e encontrados a camiseta, o tênis e o capacete utilizados por ele na ação criminosa (fls. 10/13 e 22).

De mais a mais, o aparelho celular do réu foi apreendido e, autorizado o acesso aos dados contido no mesmo (fl. 35), foi elaborada prova pericial, a qual constatou diálogo via aplicativo de troca de mensagens Whatsapp, em intervalo de tempo próximo ao horário da ocorrência do roubo, entre o réu e um indivíduo, que posteriormente foi identificado como Jhoney Leonardo da Silva Santos (fls. 39/348 e 372/1968), em relação ao qual foi determinado o desmembramento dos presentes autos.

Aliás, é fundamental enfatizar que a subtração foi praticada mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, restando, igualmente, demonstrada a consumação de roubo majorado pelo concurso de agentes nas duas oportunidades.

Ora, as declarações das vítimas revelam que o réu adentrou o estabelecimento e anunciou o roubo, ameaçando-as com a arma em punho.

É certo, ainda, que para a configuração do artigo 157, § 2º-A, I, do Estatuto Repressivo, a apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível. Nesse sentido:

Roubo majorado – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo – Prescindibilidade da apreensão e perícia do

artefato - Palavra da vítima - Pleito de afastamento prejudicado - Recurso improvido. Calamidade pública - Não comprovação de que a pandemia tenha influenciado ou facilitado a ação dos apelantes - Recurso provido em parte para afastar a agravante. Artigo 68, parágrafo único do Código Penal - Dispositivo que pode não ser aplicado a depender das circunstâncias do caso concreto - Elevada reprovabilidade da conduta que justifica o seu afastamento - Recurso improvido. Causa de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Frações aplicadas de forma autônoma - Cúmulo de aumentos leva ao estabelecimento de quarta etapa no sistema trifásico - Impossibilidade - Recurso provido em parte para somar os acréscimos e operar aumento único na terceira fase. Falsa identidade - Crime apenado com detenção - Regime deve ser fixado separadamente - Recurso provido em parte para determinar o cumprimento da pena em regime aberto. (TJSP. Apelação Criminal 1515487-33.2020.8.26.0228. Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 15/09/2021. Data de publicação: 15/09/2021).

HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO(S) CORRÉU(S). DESNECESSIDADE. COAUTOR INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) COM BASE TÃO SOMENTE NO NÚMERO DE MAJORANTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Segundo a orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em tais hipóteses, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de testemunhas. 3. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do(s) corréu(s), sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto as vítimas como as testemunhas foram uníssonas em afirmar que haviam outros integrantes na prática delitiva. Precedentes. 4. Ademais, o fato de o crime de roubo ter sido supostamente praticado na companhia de inimputável não impede o reconhecimento da causa de aumento do concurso de agentes, porquanto a razão da exacerbação da punição é justamente o maior risco que a pluralidade de pessoas ocasiona ao patrimônio alheio e à integridade física do ofendido, bem como o maior grau de intimidação infligido à vítima. 5. "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Enunciado nº 443 desta Corte. 6. Considerando a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis - tanto que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal -, bem como a quantidade de sanção corporal ora imposta, a saber, 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, cabível a fixação do regime semiaberto para início da expiação. 7. Ordem parcialmente concedida tão somente para, de um lado, reduzido para 1/3 (um terço) o patamar de exasperação por conta das causas de aumento, diminuir as reprimendas para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa; e, de outro lado, fixar o regime semiaberto para início de cumprimento da pena privativa de liberdade. (STJ; HC 197.501/SP. Relator (a): Min. OG Fernandes. Data do julgamento: 10/05/2011) (destaquei).

Inegável que no caso concreto a grave ameaça no cometimento do delito infundiu maior temor nas vítimas e as tornou mais vulneráveis à ação dos criminosos.

Quanto à causa de aumento relativa ao concurso de agentes, é importante ressaltar que este fica caracterizado apenas com a convergência de vontades para um fim comum, prescindindo-se de ajuste anterior entre os colaboradores e, aqui, vale destacar que as vítimas, bem como os policiais civis, foram uníssonas em afirmar que eram três os assaltantes no primeiro roubo e dois no segundo.

No que se refere à alegação da Defesa acerca da impossibilidade de combinação das causas de aumento de pena previstas no artigo 157, §2º e §2º-A, do Código Penal, impende frisar que, nos termos do parágrafo único do artigo 68, do referido diploma legal, a limitação a um só aumento ou a uma só diminuição, trata-se de mera faculdade do juiz, sendo possível a aplicação concomitante de duas causas especiais de aumento, se devidamente fundamentada a opção do magistrado.

Nesse sentido, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

2. No caso, o Magistrado processante apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, destacando que o crime foi praticado com a participação de quatro agentes.

3. O número de agentes, quando superior ao mínimo para a configuração do concurso de agentes, assim como a longa duração da restrição da liberdade da vítima, servem como fundamento para que o aumento da pena se dê em fração superior à mínima prevista na lei, sendo, portanto, fundamento apto a manter a incidência cumulativa das causas de aumento referentes à comparsaria, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade da vítima. Nesse contexto, não resta evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II eV, e § 2º-A, I, do Código Penal.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no HC 618.507/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021) (destaquei)

Já com relação à aplicação da Teoria da Incidência Isolada às causas de aumento de pena, outrossim pleiteada pela Defesa, há entendimento doutrinário de que as causas de aumento ou de diminuição incidem cumulativamente, ou seja, umas sobre as outras, evitando, assim, o cúmulo da pena zero e elegendo um critério uniforme para os aumentos e as diminuições.

O insigne penalista Júlio Fabbrini Mirabete, desde longa data, já endossava a impossibilidade de adoção do critério de incidência isolado em caso de concurso de causas de aumento ou de diminuição. Confira-se: “[...] Havendo várias causas de aumento ou de diminuição em quantidades fixas ou dentro de determinados limites, cada aumento ou de diminuição se opera sobre a quantidade da pena resultante da operação anterior. Não pode prevalecer a tese de que cada aumento ou diminuição deve incidir sobre a pena-base. Isto porque, havendo duas diminuições, por exemplo, de dois terços e de metade, a pena resultante seria inferior a zero, o que, evidentemente é um absurdo [...]” (In Manual de direito penal, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120 do CP. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1989, p. 309).

Dessa forma, a análise do conjunto probatório indica inexistir fragilidade probatória a ponto de propiciar a absolvição do réu.

Por todo o exposto, o quadro probatório formado ao longo da instrução autoriza a conclusão do cometimento pelo réu dos delitos previstos no artigo 157, § 2º, inciso II, e no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, em concurso material.

Concluindo pela condenação, passo à dosimetria da pena.

De acordo com o artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do réu não merece maior reprovação, pois ficou estrita à prática do delito. O réu possui antecedentes criminais (fls. 2105/2106: processo nº 0019717-96.2011.8.26.0071; fl. 2106: processo nº 0020063-08.2015.8.26.0071; fls. 2106/2107: processo nº 0022505-83.2011.8.26.0071), além da reincidência a ser considerada em momento oportuno. Nada foi apurado sobre a sua conduta social e sua personalidade, assim reputo-as em seu favor. O motivo do crime é o comum: expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia. As circunstâncias e as consequências do crime não levam à exasperação da pena. Por derradeiro, a vítima não apresentou comportamento relevante que influenciasse na dosimetria.

Destarte, havendo uma circunstância judicial contra o réu (maus antecedentes), fixo as penas no mínimo legal, aumentando-as em 1/6, resultando em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada um dos delitos de roubo.

Na segunda fase da dosimetria, não há se falar em reconhecimento da confissão espontânea, haja vista que o réu apenas admitiu parcialmente os fatos, confessando envolvimento tão somente no segundo roubo, o que não pode ser considerado para fins de atenuação da pena.

De outra banda, presente a agravante da reincidência (fl. 2103: processo nº 0000457-74.2015.8.26.0594; fls. 2103/2104: processo nº 0000484-57.2015.8.26.0594). Assim, tendo em vista se tratar de reincidência específica, majoro as penas em 1/4, ficando, então, estabelecidas no montante de 5 anos e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa para cada um dos crimes de roubo.

Na terceira fase, quanto a um dos crimes de roubo, presente a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), devendo a sanção ser majorada em 1/3, resultando em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa (sistema bifásico para a pena de multa).

No que se refere ao outro delito de roubo, também presente a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), devendo a sanção ser majorada em 1/3, resultando em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 13 dias-multa (sistema bifásico para a pena de multa). E, ainda, aplica-se a causa de aumento do artigo 157, § 2º-A, I, do Estatuto Repressivo. Assim, majoro a sanção em 2/3, resultando no montante final de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Por derradeiro, aplico a regra do concurso material (artigo 69 do Código Penal) para somar as penas dos delitos de roubo, as quais totalizam 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração para cada dia-multa, pena esta que torno definitiva em razão da inexistência de outras causas modificadoras à espécie.

Frise-se que inviável o reconhecimento da continuidade delitiva em razão do lapso temporal transcorrido entre os delitos, assim como a constatação de que o réu praticou a ação criminosa com o auxílio de diferentes comparsas em cada uma das oportunidades.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, considerando-se o disposto no artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Ademais, destaca-se a reincidência do réu e a gravidade do crime, que merece receber uma resposta enérgica do Judiciário, já que a periculosidade demonstrada justifica o regime mais rigoroso, único que atende ao princípio da suficiência na repressão e prevenção desta espécie de criminalidade.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a ameaça e a violência exercidas, o réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu RAFAEL HENRIQUE DIAS à pena de 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos para cada dia-multa, por violação ao artigo 157, § 2º, inciso II, e artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, ambos c.c. o artigo 69, todos do Código Penal, pena a ser cumprida em regime inicial fechado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento e comunique-se à Vara de Execuções Penais, Instituto de Identificação e Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, III, da Constituição Federal).

O réu respondeu ao processo custodiado. Assim, presentes os requisitos à segregação cautelar e não se alterando a situação dos autos, tanto mais diante desta decisão, a pena ora aplicada e a reincidência, bem como pelas razões já expostas às fls. 2008/2010 e, ainda, em razão da gravidade do crime praticado, o qual provoca constante desassossego na sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social e com o escopo de se resguardar a ordem pública, indefiro-lhe o recurso em liberdade nesta fase processual. Recomende-se, pois, o réu na prisão onde se encontra.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Bauru, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA